

ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ร้องสอดทั้งสองเป็นเจ้าของอาคารพิพาทโดยได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ก.ส.ล. สูง ๕ ชั้น จำนวน ๒๖ ห้อง เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ต่อมา หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบพบว่า อาคารพิพาทก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดทั้งสองระงับการก่อสร้าง ห้ามใช้หรือเข้าไปในอาคารพิพาท และให้ทำการแก้ไขและยื่นขออนุญาตหรือดำเนินการแจ้งตัดแปลงอาคารภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องสอดทั้งสองได้ดำเนินการตามคำสั่งแต่อย่างใด ปัจจุบันผู้ร้องสอดทั้งสองได้ทำการก่อสร้างตัดแปลงอาคารพิพาทจนแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการเป็นหอพักแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าหน้าที่ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายควบคุมอาคารและมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดทั้งสองแก้ไขหรือรื้อถอนอาคารตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ร้องสอดทั้งสองได้ก่อสร้างโครงเหล็กครอบดาดฟ้าทั้งหมด โดยก่อสร้างเป็นชั้นคลุมบันไดทางขึ้นชั้นดาดฟ้าเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยของอาคารโดยตรง ชั้นคลุมบันไดดังกล่าวจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของอาคารพิพาท และเป็นอาคารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ซึ่งอยู่ในบังคับที่จะต้องนำมาคำนวณความสูงของอาคารตามข้อ ๔๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่กำหนดว่า ความสูงของอาคารให้วัดแนวตั้งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของอาคารที่สูงที่สุด สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด ซึ่งเมื่อวัดอาคารพิพาทรวมถึงชั้นคลุมบันไดทำให้อาคารมีความสูงเกิน ๑๕ เมตร อาคารพิพาทจึงมีลักษณะขัดต่อข้อ ๕๐ วรรคสอง ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวและขัดต่อข้อ ๕๕^{๔๖} ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ สำหรับกรณีช่องทางเดินในอาคารพิพาทนั้น เห็นว่า โดยที่ข้อ ๒๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) กำหนดว่า ช่องทางเดินในอาคารอยู่อาศัยรวมต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ร้องสอดทั้งสองได้ก่อสร้างช่องทางเดินในอาคารกว้าง

^{๔๖} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๕๕ อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร ต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ยกเว้นบ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร

อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๕ เมตร ต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

ที่ว่างตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะใช้ร่วมกับที่ว่างของอาคารอีกหลังหนึ่งไม่ได้ เว้นแต่ใช้ร่วมกับที่ว่างของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ



๑.๒๐ เมตร จึงขัดต่อข้อ ๒๑ ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ทั้งผู้ร้องสอดทั้งสองได้ยอมรับในอุทธรณ์ว่า ในเรื่องโครงสร้างของอาคารนั้นต้องแก้ไขขนาดของบันไดก่อน จึงสามารถแก้ไขในส่วนความกว้างของช่องทางเดินในอาคารได้ โดยผู้ร้องสอดทั้งสองกำลังดำเนินการแก้ไขความกว้างของช่องทางเดินในอาคารที่ละชั้น นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือชี้แจงตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ร้องสอดทั้งสองยังไม่ได้แก้ไขความกว้างของช่องทางเดินในอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงรับฟังไม่ได้ว่า ผู้ร้องสอดทั้งสองได้ดำเนินการแก้ไขช่องทางเดินในอาคารให้ถูกต้องตามข้อ ๒๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด ส่วนกรณีของห้องนอนในอาคาร โดยที่ข้อ ๑๙ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ กำหนดว่า อาคารอยู่อาศัยรวมต้องมีพื้นที่ภายในแต่ละหน่วยที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ห้องนอนตามแบบแปลนมีพื้นที่ ๒๐ ตารางเมตร แต่การก่อสร้างจริงมีพื้นที่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร จึงขัดต่อข้อ ๑๙ ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว และในส่วนของบันไดหนีไฟ เมื่ออาคารพิพาทเป็นอาคารสูง ๕ ชั้น และสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร ซึ่งจากรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าบันไดหนีไฟมีความกว้างประมาณ ๗๒ เซนติเมตร ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศาลว่าการก่อสร้างบันไดหนีไฟไม่เป็นไปตามแบบ ซึ่งขัดต่อข้อ ๒๗^{๔๗} และข้อ ๓๐^{๔๘} ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน จึงเป็นกรณีที่ผู้ร้องสอดทั้งสองมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดทั้งสองทำการแก้ไขและยื่นขออนุญาตหรือดำเนินการแจ้งตัดแปลงอาคารแล้วไม่ปรากฏว่าผู้ร้องสอดทั้งสองได้ดำเนินการตามคำสั่งแต่อย่างใด ทั้งยังปรากฏว่าผู้ร้องสอดทั้งสองได้ดำเนินการก่อสร้างตัดแปลงอาคารให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน รวม ๔ รายการ ดังกล่าวข้างต้นจนแล้วเสร็จและเปิดให้บุคคลภายนอกเช่าอยู่อาศัยแล้ว จึงเป็นกรณีที่ผู้ร้องสอดทั้งสองมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติ

^{๔๗-๔๘} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๒๗ อาคารที่สูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปและสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร หรืออาคารที่สูงสามชั้นและมีดาดฟ้าเหนือชั้นที่สามที่มีพื้นที่เกิน ๑๖ ตารางเมตร นอกจากมีบันไดของอาคารตามปกติแล้ว ต้องมีบันไดหนีไฟที่ทำด้วยวัสดุทนไฟอย่างน้อยหนึ่งแห่ง และต้องมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟนั้นได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง

ข้อ ๓๐ บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร มีผนังที่ปิดสร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟกันโดยรอบ เว้นแต่ส่วนที่เป็นช่องระบายอากาศและช่องประตูหนีไฟ และต้องมีอากาศถ่ายเทจากภายนอกอาคารได้ โดยแต่ละชั้นต้องมีช่องระบายอากาศที่เปิดสู่ภายนอกอาคารได้มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑.๔ ตารางเมตร กับต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืน



ดังกล่าวดำเนินการสั่งให้ผู้ร้องสอดทั้งสองรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าไม่มีการรื้อถอนอาคารตามคำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็มีอำนาจตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดำเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้เองต่อไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพียงแต่มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ร้องสอดทั้งสองเร่งรัดดำเนินการตัดแปลงอาคารให้ถูกต้องเท่านั้น ไม่อาจอ้างได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดโดยครบถ้วนแล้ว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แม้จะได้มอบอำนาจในการปฏิบัติราชการในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว แต่ก็ยังคงมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามนัยมาตรา ๔๐^{๔๙} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกัน พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดำเนินการให้มีการรื้อถอนอาคารพิพาทที่ก่อสร้างตัดแปลงอาคารโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารทั้ง ๔ รายการให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๒/๒๕๕๕)

ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีคำสั่งให้ผู้ก่อสร้างอาคารโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไขตามคำสั่ง และไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกคำสั่งให้มีการรื้อถอนอาคารส่วนที่ก่อสร้างโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กรณีถือว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

^{๔๙} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๔๐ ในการมอบอำนาจตามมาตรา ๓๘ (๔) ถึง (๑๑) ให้ผู้มอบอำนาจพิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่งของผู้รับมอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจดังกล่าว

เมื่อได้มอบอำนาจแล้ว ผู้มอบอำนาจมีหน้าที่กำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ และให้มีอำนาจแนะนำและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนต่อผู้อำนวยการเขตพญาไท (ผู้ถูกฟ้องคดี) ว่า นาง ป. (ผู้ร้องสอด) ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้ก่อสร้างอาคาร ๔ ชั้น โดยอาคารด้านที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ทำเป็นผนังมีช่องเปิดเป็นหน้าต่างและช่องระบายอากาศ โดยไม่เว้นระยะห่างแนวเขตที่ดินตามที่กฎหมายกำหนด แต่ภายหลังจากการร้องเรียน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการให้เจ้าของอาคารดังกล่าวเว้นระยะผนังของอาคารด้านที่มีช่องเปิดให้ห่างจากเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนด อันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ร้องสอดทำการก่อสร้างอาคารผิดจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตและขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมบางส่วน กล่าวคือ (๑) พื้นชั้นลอยมีการก่อสร้างเติมพื้นที่ ซึ่งเป็นการผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตและขัดหรือแย้งกับข้อ ๒๒^{๕๐} และข้อ ๒๗ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และข้อ ๕๒ (๖)^{๕๑} ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ (๒) ตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ด้านทิศเหนือ พื้นชั้นลอย พื้นชั้น ๒ และชั้น ๓ ริมผนังอาคารที่บและริมปลายกันสาดห่างแนวเขตที่ดินข้างเคียง ๑.๕๐ เมตร

^{๕๐} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๒๒ ห้องหรือส่วนของอาคารที่ใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีระยะตั้งไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ห้องในอาคารซึ่งมีระยะตั้งระหว่างพื้นถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งตั้งแต่ ๕ เมตรขึ้นไป จะทำพื้นชั้นลอยในห้องนั้นก็ได้ โดยพื้นชั้นลอยดังกล่าวต้องมีเนื้อที่ไม่เกินร้อยละสี่สิบของเนื้อที่ห้อง ระยะตั้งระหว่างพื้นชั้นลอยถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร และระยะตั้งระหว่างพื้นห้องถึงพื้นชั้นลอยต้องไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร ด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๕๑} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๕๒ อาคารแต่ละหลังหรือหน่วยต้องมีที่ว่างตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๖) อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า อาคารสาธารณะ อาคารสูงเกิน ๒ ชั้นหรือสูงเกิน ๘ เมตร ยกเว้นอาคารอยู่อาศัยสูงไม่เกิน ๓ ชั้น ที่ไม่อยู่ริมทางสาธารณะ ให้มีที่ว่างด้านหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

อาคารตามวรรคหนึ่งถ้าสูงเกิน ๓ ชั้น ให้มีที่ว่างกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร

ที่ว่างตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องมีพื้นที่ต่อเนื่องกันยาวไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๖ ของความยาวเส้นรอบรูปภายนอกอาคารโดยอาจรวมที่ว่างด้านข้างที่ต่อเชื่อมกับที่ว่างด้านหน้าอาคารด้วยก็ได้ และที่ว่างนี้ต้องต่อเชื่อมกับถนนภายในกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตรออกสู่ทางสาธารณะได้ ถ้าหากเป็นถนนลอดใต้อาคาร ความสูงสุทธิของช่องลอดต้องไม่น้อยกว่า ๕ เมตร

ที่ว่างนี้อาจใช้ร่วมกับที่ว่างของอาคารอื่นได้



แต่ในการก่อสร้างจริงทำการก่อสร้างอาคารชิดติดที่ดินข้างเคียง ชัดหรือแย้งกับข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ และริมผนังอาคารมีช่องเปิดหน้าต่างหรือช่องแสง ห่างแนวเขตที่ดินข้างเคียงน้อยกว่า ๒ เมตร ชัดหรือแย้งกับข้อ ๕๔ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ และข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ อาคารด้านทิศตะวันตก ริมผนังอาคารมีช่องเปิดหน้าต่างหรือช่องแสง ห่างแนวเขตที่ดินข้างเคียงน้อยกว่า ๒ เมตร ชัดหรือแย้งกับข้อ ๕๔ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ และข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ (๓) ทำการเจาะช่องพื้นชั้น ๔ เป็นทางขึ้น-ลง ชั้นดาดฟ้าโดยมีการก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ขึ้น-ลง ระหว่างพื้นชั้น ๔ กับชั้นดาดฟ้า และมีการก่อสร้างซุ้ม ค.ส.ล. คลุมบันไดชั้นดาดฟ้าเพิ่มเติม ซึ่งขัดกับแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต อันเป็นการเพิ่มเติมผิดจากแบบแปลน ชัดหรือแย้งกับ (๒)^{๕๒} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ส่วนผนังอาคารด้านหลัง มีระยะถอยร่นห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียงน้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร (ประมาณ ๐.๔๖ เมตร) ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ คำสั่งให้ระงับ การก่อสร้างอาคารจนกว่าจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ คำสั่งห้ามใช้พื้นที่ชั้นลอยส่วนที่ก่อสร้างผิดจากแบบฯ ช่องบันไดที่ขึ้นชั้นดาดฟ้า และพื้นที่ชั้นดาดฟ้า ช่องหน้าต่างผนังด้านทิศเหนือและทิศตะวันตก จนกว่าจะจัดการแก้ไข

^{๕๒} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาต ให้กระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะ ขอบเขต แบบ หรือรูปทรงของโครงสร้างของอาคาร เว้นแต่

(ก) สัดส่วนโครงสร้างของอาคารจะผิดไปจากแบบแปลนหรือรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตเกินร้อยละห้า หรือ

(ข) เมื่อผู้คำนวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณตามมาตรา ๒๘ เห็นว่ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายโครงสร้างของอาคาร เพื่อความมั่นคงแข็งแรง โดยไม่ทำให้ลักษณะแบบ รูปทรง เนื้อที่ และที่ตั้งของอาคารผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาต และได้แจ้งให้ผู้ควบคุมงานและเจ้าของอาคารทราบแล้ว พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบโดยมีเหตุผลแสดงความจำเป็นพร้อมด้วยแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณโครงสร้างของอาคารส่วนนั้นแล้ว ทั้งนี้ ต้องแจ้งก่อนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร สิ้นอายุ

ฯลฯ

ฯลฯ

ให้ถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และคำสั่งที่ให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารให้ถูกต้องโดยให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารภายใน ๓๐ วัน ผู้ร้องสอดได้รับคำสั่งโดยชอบแล้ว แต่ไม่อุทธรณ์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คำสั่งทั้งสามฉบับจึงเป็นที่สุด ผู้ร้องสอดต้องยอมรับและปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติเช่นกันว่า ผู้ร้องสอดมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสั่งที่ให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารในส่วนต่าง ๆ ให้ถูกต้องและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารภายในระยะเวลาที่ระบุในคำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่จะต้องออกคำสั่งให้ผู้ร้องสอดรื้อถอนอาคารส่วนที่ก่อสร้างผิดแบบและขัดต่อกฎหมายควบคุมอาคาร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้อาศัยบทบัญญัติแห่งอำนาจดังกล่าวออกคำสั่งให้ผู้ร้องสอดรื้อถอนอาคารส่วนที่ก่อสร้างผิดแบบและขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารทั้งที่ผู้ร้องสอดมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ระบุให้ดำเนินการ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดรื้อถอนอาคารพิพาทที่ก่อสร้างดัดแปลงอาคารโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ให้เสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๙/๒๕๕๖)

การพิจารณาว่าเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้ให้ความยินยอมให้มีการก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินหรือไม่นั้น นอกจากการทำหนังสือยินยอมโดยชัดแจ้งแล้ว ยังอาจพิจารณาถึงพฤติการณ์ที่แสดงออกถึงการตกลงหรือยินยอมโดยปริยายเช่นว่านั้น ก็ได้ ดังนั้น ในกรณีข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เจ้าของที่ดินแปลงติดกันได้รู้เห็นถึงการก่อสร้างอาคารพิพาทชิดเขตหรือมีระยะห่างน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดมาโดยตลอด โดยไม่มีการทักท้วงหรือร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในกรณีเช่นนี้ แม้ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการทำหนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารพิพาทชิดเขต แต่พฤติการณ์ข้างต้นของเจ้าของที่ดินข้างเคียงย่อมถือได้ว่า ยินยอมให้มีการก่อสร้างอาคารชิดเขตได้โดยปริยายแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงไม่จำเป็นต้องสั่งให้มีการรื้อถอนอาคารส่วนที่ก่อสร้างชิดเขตด้วยเหตุดังกล่าว

ในการก่อสร้างอาคารชิดเขต ข้อ ๕๖ ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ ห้ามมิให้มีหน้าต่าง ประตู หรือช่องระบายลมในด้านที่ชิดเขตนั้น การก่อสร้างผนังด้านดังกล่าวโดยมีบานพลาสติกติดตึงถาวรเพื่อให้แสงสว่างลอดได้



แม้ไม่สามารถเปิดปิดหรือระบายอากาศได้ก็ถือเป็นการขัดต่อกฎกระทรวงดังกล่าว
 แม้ต่อมาจะมีการแก้ไขด้วยการใช้แผ่นไม้อัดปิดช่องแสงช่องลมด้านในของตัวอาคาร
 ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นการแก้ไขให้เป็นผนังทึบแล้วตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังคงมีหน้าที่ต้องสั่งให้มีการแก้ไขผนังดังกล่าวรวมถึงกรณีที่ไม่
 ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกรณีอื่นที่ให้ออกต้องตามกฎหมายด้วย
 โดยดำเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติ
 ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นยังไม่ดำเนินการดังกล่าว
 จึงถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อประมาณต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๓ นาย ฐ. ได้ขอรับใบอนุญาต
 ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น เป็นหอพักในที่ดินที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีด้านทิศตะวันตก
 แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ยังไม่ออกใบอนุญาต
 ให้ก่อสร้างอาคาร เนื่องจากอาคารชิดแนวเขตที่ดินข้างเคียงน้อยกว่า ๒ เมตร และไม่มีหนังสือ
 ยินยอมให้ชิดเขต เจ้าพนักงานท้องถิ่นในขณะนั้นได้เรียกผู้ฟ้องคดีและนาย ฐ. มาทำความเข้าใจ
 ผู้ฟ้องคดีได้เสนอเงื่อนไขให้ทำบันทึกข้อตกลงว่านาย ฐ. จะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหาย
 ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีจึงยินยอมลงลายมือชื่อ
 ในบันทึกดังกล่าว ปรากฏตามบันทึก ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ออก
 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้นาย ฐ. ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าหนังสือยินยอมให้ชิดเขต
 ที่ดินได้สูญหายไปในการย้ายสำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ฐ. ได้มีการโอน
 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหอพักฉบับนี้ให้แก่นางสาว พ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) หลังจากนั้น
 ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า นาย ฐ. ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน
 ของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีไม่เคยยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน อาคารที่พิพาททำให้
 ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อน เพราะผู้อยู่อาศัยในอาคารดังกล่าวได้ทิ้งสิ่งของและขยะลงบน
 หลังคาบ้านของผู้ฟ้องคดี รวมทั้งท่อระบายน้ำฝนได้ปล่อยน้ำฝนลงบนพื้นทำให้น้ำซึมเข้าในบ้าน
 ของผู้ฟ้องคดี โดยนาย ฐ. ไม่เคยรับผิดชอบตามบันทึกข้อตกลง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบ
 ข้อร้องเรียนแล้วเห็นว่า การก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น ไม่ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๕๕
 (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงออกคำสั่ง
 ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอนช่องแสงช่องลมทั้งหมดในส่วนที่ติดต่อกับเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีและ
 ให้ปิดเป็นผนังทึบตลอดแนว ส่วนกรณีท่อน้ำทิ้งที่อยู่ระหว่างอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น และติดกับ
 บ้านของผู้ฟ้องคดีมีปลายท่ออยู่สูงจากพื้นไม่ได้ต่อลงท่อน้ำทิ้งของเทศบาล ทำให้เมื่อฝนตก
 น้ำฝนจะไหลซึมเข้ามาข้างภายในบ้านของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าได้แนะนำให้ทั้งสองฝ่าย
 ทำบ่อพักน้ำเชื่อมต่อลงท่อระบายน้ำสาธารณะแล้ว นอกจากนั้น ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๓

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น สูงไม่เกิน ๙ เมตร เพื่อเป็นบ้านพักอาศัยซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีด้านทิศตะวันออกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนว่าอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก่อสร้างห่างจากเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีน้อยกว่า ๒ เมตร โดยผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบพบว่าหน้าต่าง ช่องแสง เป็นแบบโปร่งแสง และตัวอาคารเว้นระยะห่างเขตที่ดินน้อยกว่า ๒ เมตรจริง จึงออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอนหน้าต่าง ช่องแสง และระเบียบด้านที่ดินติดกับเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างเป็นผนังทึบสูง ๑.๘๐ เมตร รวมทั้งให้ติดตั้งน้ำที่ชายคาด้านที่ชิดเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าหลังจากมีคำสั่งไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ปิดช่องแสง ช่องลมอาคารทั้งสองแห่งด้วยแผ่นไม้อัดด้านในอาคาร และติดตั้งน้ำที่ชายคาบ้านแล้ว สำหรับชายคาที่พักอาศัย ๒ ชั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาคารและเป็นส่วนฐานรากของอาคารจึงสามารถขีดแนวเขตที่ดินได้ และชายคาดังกล่าวไม่ได้ยื่นล้ำเข้าไปในรั้วบ้านของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่านาย ฐ. และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่ได้ทำการแก้ไขตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ฐ. กับผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือบันทึกข้อความ มีสาระสำคัญว่า นาย ฐ. ได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น ติดกับบ้านของผู้ฟ้องคดี โดยตกลงกันว่า ในระหว่างที่ทำการก่อสร้างอาคาร นาย ฐ. จะรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด โดยนาย ฐ. ลงชื่อเป็นผู้ขออนุญาต ส่วนผู้ฟ้องคดีลงชื่อเป็นผู้ขีดเขตที่ดิน หนังสือดังกล่าวทำเป็น ๓ ฉบับ ต่างฝ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับ อีกฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐานที่สำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุญาตให้นาย ฐ. ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น (หอพัก) และนาย ฐ. ได้โอนใบอนุญาตก่อสร้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยอาคารดังกล่าวได้ก่อสร้างห่างจากแนวเขตที่ดินผู้ฟ้องคดีน้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ซึ่งการพิจารณาว่ามีการให้ความยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินตามกฎหมายหรือไม่นั้น อาจพิจารณาได้จากพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการตกลงหรือการให้ความยินยอมจากผู้ฟ้องคดี จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า บันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อมูลหลักฐานประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ซึ่งในช่องลงลายมือชื่อระบุว่านาย ฐ. ผู้ขออนุญาต และผู้ฟ้องคดีผู้ขีดเขตที่ดิน แสดงว่า ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องรู้เห็นการก่อสร้างอาคารที่พิพาทชิดเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่ผู้ฟ้องคดีก็มิได้ทักท้วงผู้ดำเนินการก่อสร้าง หรือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกี่ยวกับระยะห่างของอาคารในระหว่างก่อสร้างแต่อย่างใด และเมื่ออาคารที่พิพาทก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีก็เพียงแต่ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากอาคารข้างเคียงเนื่องจากเวลาฝนตกมีน้ำไหลเข้าบ้านทำให้ทรัพย์สินเสียหายเท่านั้น เมื่อพิจารณา



จากหลักฐานข้อตกลงรวมทั้งการลงลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขีดเขตที่ดินประกอบกับพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ยินยอมให้นาย ธ. ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น ขีดเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยปริยายแล้ว

ในส่วนของอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ระเบียบของอาคารเว้นระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีน้อยกว่า ๒ เมตร โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ฟ้องคดี และขายอาคารไปก่อสร้างขีดเขตที่ดินผู้ฟ้องคดี แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีย่อมต้องรู้เห็นการก่อสร้างอาคารที่พิพาทขีดเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ได้ทักท้วงผู้ดำเนินการก่อสร้างหรือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกี่ยวกับระยะห่างของอาคารในระหว่างก่อสร้างแต่อย่างใด จนกระทั่งอาคารที่พิพาทก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือร้องเรียนต่ออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าอาคารดังกล่าวก่อสร้างขีดที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยผิดกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ยินยอมให้นาย ธ. ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น ขีดเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยปริยายแล้วเช่นเดียวกัน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอนอาคารพิพาท ค.ส.ล. ๓ ชั้น และ ๒ ชั้น ในส่วนที่ขีดแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่เนื่องจากอาคารพิพาทเป็นอาคารเกินสองชั้นขึ้นไป หากก่อสร้างขีดเขตที่ดินน้อยกว่า ๓๐๐ เซนติเมตร ต้องห้ามมิให้มีหน้าต่าง ประตู หรือช่องระบายลมในด้านที่ชิดกับเขตที่ดินนั้น ทั้งนี้ ตามข้อ ๕๖^{๕๓} ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผนังอาคารบางส่วนของอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีบานพลาสติกติดตึงถาวรเพื่อให้แสงสว่างลอดได้ แต่ไม่สามารถเปิดปิดหรือระบายอากาศได้ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจพบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอนช่องแสงช่องลมทั้งหมดในส่วนที่ติดต่อกับเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีและให้ปิดเป็นผนังทึบตลอดแนวภายใน ๓๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการแก้ไขด้วยการใช้แผ่นไม้อัดปิดช่องแสงช่องลมด้านในของตัวอาคาร เห็นได้ว่าการกระทำดังกล่าวมิใช่เป็นผนังทึบ กรณีถือได้ว่าการดำเนินการแก้ไขช่องแสงช่องลมยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายฉบับดังกล่าว ซึ่งเรื่องช่องแสงช่องลมไม่เป็นผนังทึบเป็นกรณี

^{๕๓} กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๕๓๙

ข้อ ๕๖ อาคารที่ปลูกชิดกับที่ดินของผู้อื่น หรือชิดกับอาคารอีกหลังหนึ่งนั้น ถ้ามีระยะห่างน้อยกว่า ๒๐๐ เซนติเมตร สำหรับอาคารสองชั้นลงมา หรือน้อยกว่า ๓๐๐ เซนติเมตร สำหรับอาคารสองชั้นขึ้นไป ห้ามมิให้มีหน้าต่าง ประตู หรือช่องระบายลมในด้านที่ชิดกับเขตที่ดินหรืออาคารอื่นนั้น

อย่างไรก็ตามอาคารที่ปลูกชิดกับที่ดินของผู้อื่นนั้นจะมีระยะห่างจากเขตที่ดินนั้นต่ำกว่า ๕๐ เซนติเมตร ไม่ได้เว้นแต่จะปลูกสร้างโดยวิธีตกลงทำผนังร่วมกัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียประโยชน์ในทางสถาปัตยกรรม



ที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือทึบให้ผู้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการใหม่ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว คือ ต้องมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการรื้อถอนช่องแสงช่องลมที่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือทึบภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องดำเนินการตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

ในส่วนของทอระบายน้ำฝนของอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น (หอพัก) ไม่ได้ต่อลงทอระบายน้ำของเทศบาล เวลาฝนตกหนักทำให้น้ำฝนไหลซึมและขังในบ้านของผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๒ กำหนดว่า อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงต้องมีการระบายน้ำฝนออกจากอาคารที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นหรือเกิดน้ำไหลนองไปยังที่ดินอื่นที่มีเขตติดต่อกับเขตที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอาคารนั้น วรรคสอง กำหนดว่า การระบายน้ำฝนออกจากอาคารตามวรรคหนึ่งจะระบายสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้งโดยตรงก็ได้ ซึ่งกรณีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าได้แนะนำให้ทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำบ่อพักน้ำเชื่อมต่อลงทอระบายน้ำสาธารณะแล้ว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/ปลัดเทศบาล ว่า กรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากท่อน้ำทิ้งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ปล่อยน้ำใช้ลงทางสาธารณะไหลผ่านหน้าบ้านของตน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แก้ไขโดยทำบ่อพักน้ำและเชื่อมต่อลงทอระบายน้ำสาธารณะแล้ว ส่วนความเดือดร้อนและเสียหายจากน้ำไหลซึมเข้าภายในบ้านผู้ฟ้องคดี เกิดจากน้ำฝนที่ตกลงมาปะทะตัวอาคาร ๓ ชั้น แล้วไหลมาตามตัวอาคารซึมลงรอยต่อระหว่างอาคารที่ปลูกสร้างชิดเขตกัน ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ แต่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ยังคงมีน้ำไหลซึมเข้ามายังบ้านของผู้ฟ้องคดี เมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายที่คู่กรณีส่งต่อศาลแล้วเห็นว่า ทอระบายน้ำฝนที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างอยู่นอกอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น โดยอยู่ระหว่างอาคารของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ท่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้ไขแล้ว และมีบ่อพักน้ำอยู่ภายในอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น เป็นท่อน้ำทิ้ง มิใช่ทอระบายน้ำฝนที่พิพาทกันในคดีนี้ จึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังมีได้แก้ไขให้ถูกต้องและเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ข้อ ๒ ดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังคงมีหน้าที่สั่งให้



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการแก้ไขให้ผู้ถูกต้องและดำเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมิได้ดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการแก้ไขช่องแสงช่องลมของอาคารที่พิพาททั้งสองหลังด้านที่ติดกับเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีและออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการแก้ไขท่อระบายน้ำฝนด้านหลังอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น ที่ก่อสร้างชิดเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้ผู้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามลำดับตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๓/๒๕๕๘)

๑.๔ ข้อพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดำเนินการ

๑.๔.๑ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถูกต้องได้

ในกรณีที่มีการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่จะออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารดังกล่าวดำเนินการแก้ไขอาคารที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือสั่งให้มีการยื่นขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคารให้ผู้ถูกต้องได้ แต่หาไม่อำนาจที่จะมีคำสั่งให้ผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ลูกจ้าง หรือบริวารของเจ้าของบุคคลดังกล่าวกระทำการแก้ไขแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้ผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่ได้มีฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารดังกล่าวดำเนินการแก้ไขอาคารส่วนที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต และให้ยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคารให้ผู้ถูกต้อง จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองอาคารที่เป็นมูลพิพาทและปรากฏในสำเนาทะเบียนบ้านว่าเป็นเจ้าบ้านซึ่งได้มีการก่อสร้างดัดแปลงอาคารดังกล่าวด้านหลัง (อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว) เพื่อใช้เป็นห้องครัว โดยต่อเติมผนังจากรั้วเดิมซึ่งเป็นรั้วร่วม และมุงหลังคากระเบื้อง

เขตที่ดินต่างผู้ครอบครอง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง และไม่ได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจพบ อาคารดังกล่าวได้ทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคารส่วนที่ก่อสร้างดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต และสั่งให้ทำการรื้อถอนอาคารส่วนที่ก่อสร้างดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งทั้งสองคำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตจังหวัดนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัย ให้ยกอุทธรณ์กรณีคำสั่งห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารฯ ส่วนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีทำการรื้อถอนอาคารส่วนที่ก่อสร้างดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต เห็นว่า การก่อสร้างดัดแปลงอาคารพิพาทเป็นกรณีที่ยังสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ จึงให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาออกคำสั่งใหม่ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งอีกครั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขอาคารส่วนที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยให้แก้ไขเป็นผนังทึบห่างจากเขตที่ดินต่างผู้ครอบครองอย่างน้อย ๐.๕๐ เมตร และให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากอาคารเป็นของนาย ว. ผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้านเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีไม่มีอำนาจในการแก้ไขหรือต่อเติมอาคารหรือกระทำการใด ๆ ตามคำสั่ง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า ได้มีการก่อสร้างดัดแปลงอาคารพิพาทด้านหลังเพื่อใช้เป็นห้องครัว โดยต่อเติมผนังจากรั้วเดิมซึ่งเป็นรั้วร่วม และมุงหลังคากระเบื้อง เขตที่ดินต่างผู้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และไม่มีการแจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งยังไม่ได้ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของบ้านและที่ดินข้างเคียง อันถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจตามตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่จะออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารดังกล่าวยื่นคำขออนุญาตหรือดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ และดำเนินการ



แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยหาได้มีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ลูกจ้าง หรือบริวารของเจ้าของอาคารหรือของบุคคลดังกล่าวกระทำการดังกล่าวแต่อย่างใดไม่ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้แต่เพียงว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองอาคาร และมีชื่อเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านดังกล่าวอยู่ในเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจพบว่าการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารดังกล่าวโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร แต่การมีชื่อผู้ฟ้องคดีในทะเบียนบ้านดังกล่าวว่าเป็นเจ้าบ้านหาใช่พยานหลักฐานเพียงพอที่จะแสดงว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านหรืออาคารหลังดังกล่าวไม่ อีกทั้ง ยังได้ความจากคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีและนาย ว. พร้อมพยานหลักฐานประกอบคำชี้แจงตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดว่า อาคารพิพาทเป็นของนาย ว. มิใช่บ้านของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขอาคารพิพาทส่วนที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต และให้ยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคารให้ถูกต้อง จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกรณียอมเป็นเหตุให้การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๐/๒๕๕๖)

กรณีที่เจ้าของอาคารทำการดัดแปลงอาคารโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อีกทั้ง ยังปรากฏว่าการดัดแปลงอาคารดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายในเรื่องที่วางที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการดัดแปลงอาคาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่จะออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดได้ แม้ว่ากฎกระทรวงฉบับดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับภายหลังจากที่เจ้าของอาคารทำการดัดแปลงแล้วก็ตาม เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวเป็นคุณกับเจ้าของอาคาร โดยทำให้เจ้าของอาคารสามารถก่อสร้างรั้วแบ่งกันตามแนวเขตที่ดินด้านหลังอาคารและสามารถขออนุญาตต่อเติมดัดแปลงอาคารเพิ่มได้อีก ๑ เมตรจากแนวผนังอาคาร จึงทำให้กรณีนี้เป็นกรณีที่สามารแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับการร้องเรียนว่า มีการก่อสร้างดัดแปลงอาคารโดยมิได้รับอนุญาต นายช่างโยธา ๓ สำนักงานเขตทุ่งครุ ได้ตรวจสอบอาคารดังกล่าวและพบว่าอาคารที่ก่อสร้างโดยบริษัท ท. ซึ่งมีอาคารของผู้ฟ้องคดีทั้งสองรวมอยู่ด้วย โดยห้องแถวหรือตึกแถวของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีการดัดแปลงอาคาร ค.ส.ล.



ขนาด ๓ x ๔ เมตร และสูงประมาณ ๙ เมตร เชื่อมหลังอาคารเดิมปกคลุมที่ว่างทางเดินหลังอาคาร โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองระงับการดัดแปลงอาคาร ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร และให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิได้ปฏิบัติตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการรื้อถอนอาคารในส่วนที่ก่อสร้างดัดแปลงโดยมิได้รับอนุญาตให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของทาวนเฮาส์ ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสุขสวัสดิ์สวนธน ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ได้ทำการดัดแปลงอาคารชนิด ค.ส.ล. ขนาด ๓ x ๔ เมตร และสูงประมาณ ๙ เมตร เชื่อมหลังอาคารเดิมปกคลุมที่ว่างทางเดินหลังอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ดัดแปลงอาคารปกคลุมที่ว่างทางเดินหลังอาคารจนเต็มพื้นที่ เป็นผลให้ไม่มีที่ว่างด้านหน้าอาคาร ซึ่งการต่อเติมอาคารพิพาท ลักษณะดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เป็นการกระทำอันมีลักษณะการดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงขัดต่อมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และขัดต่อข้อ ๗๖^{๕๔} ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร

^{๕๔} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๗๖ อาคารประเภทต่าง ๆ จะต้องมียี่ว้างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่าส่วนที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

- (๑) อาคารที่พักอาศัยแต่ละหลังให้มีที่ว่างอยู่ ๓๐ ใน ๑๐๐ ส่วนของพื้นที่
- (๒) อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสาธารณะซึ่งไม่ได้ใช้เป็นที่พักอาศัย ให้มีที่ว่างอยู่ ๑๐ ใน ๑๐๐ ส่วนของพื้นที่ แต่ถ้าใช้เป็นที่พักอาศัยด้วยให้มีที่ว่างอยู่ ๓๐ ใน ๑๐๐ ส่วนของพื้นที่
- (๓) ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสาธารณะสูงไม่เกินสามชั้น และไม่อยู่ริมทางสาธารณะต้องมีที่ว่างด้านหน้าอาคารไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร ถ้าสูงเกินสามชั้นต้องมีที่ว่างด้านหน้าอาคารไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร

ในกรณีที่อาคารหันหน้าเข้าหากันให้มีที่ว่างร่วมกันได้

ในกรณีที่หันหน้าตามกัน ให้ที่ว่างด้านหน้าของอาคารแถวหลังเป็นทางเดินหลังอาคารของอาคารแถวหน้าด้วย

- (๔) ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสาธารณะจะต้องมียี่ว้างโดยปราศจากสิ่งปกคลุมเป็นทางเดินหลังอาคารได้ถึงกันกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร โดยให้แสดงเขตดังกล่าวให้ปรากฏด้วย

ในกรณีที่อาคารหันหลังเข้าหากัน จะต้องเว้นทางเดินด้านหลังไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร



พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ อันเป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการดัดแปลงอาคาร อย่างไรก็ดี โดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า อาคารของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเป็นห้องแถวหรือตึกแถว ๓ ชั้น โดยเว้นที่ว่างทางเดินไว้ ๓ เมตร จึงยังเหลือพื้นที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองสามารถขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอาศัยอำนาจตามมาตราดังกล่าวมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการ (ก) แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามรายการดังต่อไปนี้ บ้านแถวต้องมีที่ว่างด้านหน้าระหว่างรั้วถึงแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร และต้องมีที่ว่างด้านหลังรั้วถึงแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร อาคารพักอาศัยต้องมีที่ว่าง ๓๐ ใน ๑๐๐ ส่วน ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง และ (ข) ยื่นคำขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันพ้นกำหนดตาม (ก) จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๓๓ (๑)^{๕๕} และข้อ ๓๖ วรรคหนึ่ง^{๕๖} แม้กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทำการดัดแปลงแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวเกี่ยวกับที่ว่างของอาคารพักอาศัยตามข้อ ๓๖ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวเป็นคุณกับผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองสามารถก่อสร้างรั้วแบ่งกันตามแนวเขตที่ดินด้านหลังอาคาร และสามารถขออนุญาตต่อเติมดัดแปลงอาคารได้ ๑ เมตรจากแนวผนังอาคาร คำสั่งดังกล่าวจึงนำมาใช้บังคับกับกรณีของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารให้ถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนดในคำสั่งดังกล่าว ฉะนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

(๕) ห้องแถว ตึกแถว และอาคารพาณิชย์ ที่ตั้งอยู่ริมถนนสองสายติดกัน และมีทางออกสู่ด้านหน้าทั้งสองสายในระยะไม่เกิน ๑๕ เมตร จากมุมถนนสองสาย หรือตั้งอยู่ริมทางสาธารณะสองสายขนานอยู่ ทางสายใดสายหนึ่งกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร ทางขนานกันนั้นห่างจากกันไม่เกิน ๑๕.๐๐ เมตร และได้รั้นแนวอาคารตามข้อ ๗๒ แล้ว จะไม่มีที่ว่างหรือทางเดินหลังอาคารก็ได้

^{๕๕-๕๖} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๓๓ อาคารแต่ละหลังหรือหน่วยต้องมีที่ว่างตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) อาคารอยู่อาศัย และอาคารอยู่อาศัยรวม ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๓๐ ใน ๑๐๐ ส่วนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่ง ที่มากที่สุดของอาคาร

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๓๖ บ้านแถวต้องมีที่ว่างด้านหน้าระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร และต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

ฯลฯ

ฯลฯ

ยอมมีอำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ที่จะสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ดำเนินการรื้อถอนอาคารในส่วนที่ก่อสร้างดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันได้ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๙-๖๐๐/๒๕๕๗)

กรณีอาคารเดิมมีลักษณะเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง ซึ่งต่อมาตัวบ้านและเสาบ้านมีสภาพชำรุด เจ้าของจึงดำเนินการรื้อถอนแล้วก่อสร้างใหม่ โดยมีการสร้างเสา คาน หรือโครงสร้างชั้นใหม่ทดแทนของเดิม มีสภาพกลายเป็นอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น กรณียอมไม่อาจถือได้ว่าเป็นการซ่อมแซมเพียงเล็กน้อย แต่เป็นการก่อสร้างอาคาร จึงต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเสียก่อน เมื่อเจ้าของอาคารมิได้ยื่นขออนุญาต จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อีกทั้ง การก่อสร้างดังกล่าวยังขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าง ดังนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารระงับการก่อสร้างอาคาร ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร ให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง รวมถึงให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวที่ตรอกวังหลัง ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เจ้าของที่ดินข้างเคียงได้ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่า ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต สำนักงานเขตบางกอกน้อยตรวจสอบแล้วพบว่า อาคารของผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่อย่างใด ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงมีหนังสือแจ้งคำสั่งรวม ๓ ฉบับ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคาร คำสั่งห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร และคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขและยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเพียงแต่ซ่อมแซมบ้านตามสภาพเดิมที่ซื้อมาเท่านั้นมิได้ก่อสร้างขึ้นใหม่แต่อย่างใด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งทั้งสามฉบับของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ก่อนการทำสัญญาขายที่ดินกับผู้ฟ้องคดี ผู้ขายที่ดินพร้อมอาคารพิพาทได้แสดงรายละเอียดตัวอาคารว่า เป็นบ้านไม้ยกจากพื้นสูงสองเมตรเศษ



ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักฐานสัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมอาคารพิพาท ได้ระบุว่า ขายที่ดินพร้อมบ้านไม้ชั้นเดียว จึงเห็นได้ว่า อาคารเดิมของผู้ฟ้องคดีเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวได้ถูกสูงต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ทำการรื้อถอนบ้านหลังดังกล่าว เนื่องจากตัวบ้านและเสาบานมีสภาพชำรุดจนไม่อาจใช้เป็นที่อยู่อาศัยตามปกติได้ และดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพาท ซึ่งปรากฏตามรายงานของนายตรวจโยธาสำนักงานเขตบางกอกน้อยซึ่งออกตรวจเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ว่า ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างอาคารให้เป็นอาคาร ก.ส.ล. ๒ ชั้น ขนาด ๑๐.๐๐ x ๑๖.๐๐ เมตร สูง ๕.๔๐ เมตร ชั้นล่างสูง ๒.๔๐ เมตร ชั้นบนสูง ๓ เมตร โดยอาคารดังกล่าวก่อสร้างชิดแนวเขตที่ดินข้างเคียงผนังเป็นคอนกรีต กรณีจึงเห็นได้ว่าเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวได้ถูกรื้อถอนแล้วถูกสร้างใหม่ที่มีการสร้างเสา คานหรือโครงสร้างขึ้นใหม่เพื่อทดแทนของเดิม ซึ่งเป็นกรณีทำให้บ้านไม้ชั้นเดียวดังกล่าวเปลี่ยนสภาพไปโดยสิ้นเชิง จึงเป็นการก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๕^{๔๗} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ฉะนั้น เมื่อการก่อสร้างอาคารดังกล่าวมิใช่การกระทำที่เป็นการซ่อมแซมเพียงเล็กน้อยตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ฟ้องคดีจึงต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเสียก่อน แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นขออนุญาต จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ นอกจากนี้ การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดียังขัดต่อบทบัญญัติข้อ ๒๑ (๑)^{๔๘} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมทั้งยังเป็นกรณีที่ฝ่าฝืนต่อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร

^{๔๗} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ก่อสร้าง” หมายความว่า สร้างอาคารขึ้นใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นแทนของเดิมหรือไม่

“ดัดแปลง” หมายความว่า เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยาย ซึ่งลักษณะ ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ ของโครงสร้างของอาคาร หรือส่วนต่าง ๆ ของอาคารซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม และมีใช้การซ่อมแซม หรือการดัดแปลงที่กำหนดในกฎกระทรวง

“ซ่อมแซม” หมายความว่า ซ่อมหรือเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของอาคารให้คงสภาพเดิม

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๔๘} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๒๑ ช่องทางเดินในอาคาร ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร

ความกว้าง

๑. อาคารอยู่อาศัย

๑.๐๐ เมตร

๒. อาคารอยู่อาศัยรวม หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

๑.๕๐ เมตร

สำนักงาน อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารพิเศษ



พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕๒ (๑)^{๕๙} ข้อ ๕๔^{๖๐} และข้อ ๕๖^{๖๑} เนื่องจากดำเนินการโดยฝ่าฝืนต่อหลักเกณฑ์การก่อสร้างอาคารที่กฎหมายกำหนดไว้ กล่าวคือ การก่อสร้างอาคารต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๓๐ ใน ๑๐๐ ส่วนของพื้นที่ที่ดิน และอาคารด้านที่ชิดที่ดินเอกชน ช่องเปิดประตูหน้าต่าง ช่องระบายอากาศหรือระเบียงสำหรับชั้น ๒ ลงมาหรือสูงไม่เกิน ๙ เมตร ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๒ เมตร รวมทั้งอาคารบ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ให้ผนังด้านที่ไม่มีช่องเปิด สามารถสร้างห่างเขตที่ดินได้น้อยกว่า ๑ เมตร ถ้าห่างเขตที่ดินน้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินนั้นด้วย ดังนั้น เมื่ออาคารของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว จึงชอบที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างและห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนที่ก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวข้างต้นเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของอาคารยื่นคำขออนุญาตหรือดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องในเวลาที่กำหนด ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งได้รับมอบอำนาจจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคาร ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต และให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายใน ๓๐ วัน โดยให้ยื่นขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในเวลาที่กำหนด จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๕/๒๕๕๘)

ในการพิจารณาแบบคำขออนุญาตก่อสร้างซึ่งยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่เพียงตรวจพิจารณาคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้อง หากเห็นว่าถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มีอำนาจอนุญาตออกใบอนุญาตให้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องออกไปตรวจสอบผังบริเวณตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริงแต่อย่างใด เมื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารได้ก่อสร้าง

^{๕๙-๖๑} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๕๒ อาคารแต่ละหลังหรือหน่วยต้องมีที่ว่างตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) อาคารอยู่อาศัย ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๓๐ ใน ๑๐๐ ส่วนของพื้นที่ที่ดิน

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๕๔ อาคารด้านชิดที่ดินเอกชน ช่องเปิด ประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ หรือริมระเบียงสำหรับชั้น ๒ ลงมาหรือสูงไม่เกิน ๙ เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๒ เมตร และสำหรับชั้น ๓ ขึ้นไปหรือสูงเกิน ๙ เมตร ต้องห่างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

ข้อ ๕๖ บ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ให้ผนังด้านที่ไม่มีช่องเปิด สามารถสร้างห่างเขตที่ดินได้น้อยกว่า ๑ เมตร ถ้าห่างเขตที่ดินน้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินนั้นด้วย



อาคารผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตโดยผนังอาคารที่เป็นช่องเปิดอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินไม่ถึง ๒ เมตร อันเป็นการขัดกับข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๔๐ (๓) และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่จะออกคำสั่งให้ผู้ก่อสร้างแก้ไขอาคารดังกล่าวได้

สรุปข้อเท็จจริง

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคาร และเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมืองซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลนครนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ออกหนังสือรับรองว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำการปลูกสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่ได้รับอนุญาต และนายทะเบียนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกหมายเลขทะเบียนบ้านให้ผู้ฟ้องคดี ต่อมา มีผู้ร้องเรียนกรณีการก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดี เจ้าหน้าที่สำนักการช่างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ไปตรวจสอบและพบว่าผนังอาคารที่ก่อสร้างเป็นบ้านพักอาศัยทั้งด้านทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันออกทำเป็นช่องเปิด (หน้าต่างกระจกเปิดปิดได้) แต่ผนังอาคารทั้ง ๒ ด้านอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินไม่ถึง ๒ เมตร อันเป็นการก่อสร้างที่ผิดจากแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขผนังอาคารที่ทำเป็นช่องเปิดให้ทำเป็นผนังทึบและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยยืน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ความผิดพลาดในการก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพราะในการออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคาร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบตามเอกสารคำขออนุญาตเท่านั้นไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบผังบริเวณตามสภาพพื้นที่ที่ก่อสร้างตามความเป็นจริง และในระหว่างการก่อสร้างผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ไปตรวจการก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีตลอดเวลา แต่ก็ไม่ได้มีคำสั่งใด ๆ อีกทั้ง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมืองซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกหนังสือรับรองว่าผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่ได้รับอนุญาต และนายทะเบียนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกหมายเลขทะเบียนบ้านให้ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงยื่นฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมาย พร้อมทั้งให้ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี หากศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขผนังอาคาร

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารโดยมีผนังอาคารพิพาทด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกห่างจากแนวเขตที่ดินไม่ถึง ๒ เมตร จึงเป็นกรณีที่มีการก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีไม่ถูกต้องตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ซึ่งบทบัญญัติมาตรา ๓๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติว่า ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เป็นการฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้ควบคุมงาน เว้นแต่ผู้ควบคุมงานจะพิสูจน์ได้ว่า เป็นการกระทำของผู้อื่น ซึ่งผู้ควบคุมงานได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงการกระทำดังกล่าวให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร และผู้ดำเนินการทราบแล้ว แต่บุคคลดังกล่าวไม่ยอมปฏิบัติตาม ดังนั้น เมื่อการก่อสร้างอาคารพิพาทในคดีนี้มีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ควบคุมงานจึงต้องถือว่าการก่อสร้างที่ผิดแบบแปลนเป็นการกระทำของผู้ฟ้องคดี และเมื่อการก่อสร้างอาคารโดยการควบคุมงานของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากผนังอาคารด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตกทำเป็นช่องเปิด (หน้าต่างกระจกเปิดปิดได้) โดยไม่ทำเป็นผนังที่บอยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่า ๒ เมตร ตามข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขผนังด้านข้างของอาคารที่ทำเป็นช่องเปิดดังกล่าวให้เป็นผนังทึบ จึงเป็นการสั่งให้แก้ไขเพื่อให้อาคารที่ก่อสร้างถูกต้องตามมาตรา ๔๐ (๓) และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ประกอบข้อ ๕๐ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขผนังด้านข้างของอาคารที่ทำเป็นช่องเปิดให้เป็นผนังทึบจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน และเมื่อคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น

นอกจากนี้ ในการออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารตามกรณีพิพาทในคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจและหน้าที่เพียงตรวจพิจารณาคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้อง หากเห็นว่าถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจออกใบอนุญาตให้ได้โดยไม่จำเป็นต้องออกไปตรวจสอบผังบริเวณตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริงเสียก่อนตามข้ออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี สำหรับกรณีที่ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมืองได้ออกหนังสือรับรองว่าผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยตามที่ได้รับอนุญาต และนายทะเบียนท้องถิ่นซึ่งสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกเลขประจำบ้านให้ผู้ฟ้องคดี เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกใบรับรองว่าผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารบ้านพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อผู้ฟ้องคดีจะได้นำไปเป็นหลักฐานประกอบการขอเลขประจำบ้าน

